

<제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

[기출][2020-1-2]영업정지기간 도과 후 가중적 제재 우려가 있는 경우의 협의의 소의 이익 인정 여부

《【문제1】 甲은 2018. 11. 1.부터 A시 소재의 3층 건물의 1층에서 일반음식점을 운영해 왔는데, 관할 행정청인 A시의 시장 乙은 2019. 12. 26. 甲이 접대부를 고용하여 영업을 했다는 이유로 甲에 대하여 3월의 영업정지처분을 하였다. 이에 대하여 甲은 문제가 된 여성은 접대부가 아니라 일반 종업원이라는 점을 주장하면서 3월의 영업정지처분의 취소를 구하는 행정심판을 청구했다. 관할 행정심판위원회는 2020. 3. 6. 甲에 대한 3월의 영업정지처분을 1월의 영업정지처분으로 변경하라는 일부인용재결을 하였고, 2020. 3. 10. 그 재결서 정본이 甲에게 도달하였다. 乙은 행정심판위원회의 재결내용에 따라 2020. 3. 17. 甲에 대하여 1월의 영업정지처분을 하였고, 향후 같은 위반사유로 제재처분을 받을 경우 식품위생법 시행규칙 별표의 행정처분기준에 따라 가중적 제재처분이 내려진다는 점까지 乙은 甲에게 안내했다. 행정심판을 통해서 구제를 받지 못했다고 생각한 甲은 2020. 6. 15. 취소소송을 제기하고자 한다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 甲은 乙의 영업정지처분 1월이 경과한 후에도 그 처분의 취소를 구할 소의 이익이 있는지 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 영업정지기간 도과 후 가중적 제재 우려가 있는 경우의 협의의 소의 이익 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 행정심판의 일부인용재결에 따라 1월의 영업정지처분을 받았고, 그 영업정지기간이 모두 경과한 이후에 그 처분의 취소를 구하고자 한다. 쟁점으로 <영업정지기간이 이미 경과하여 처분의 효력이 소멸한 경우에도 甲에게 영업정지처분의 취소를 구할 소의 이익이 인정되는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲에게 乙의 영업정지처분 1월이 경과한 후에도 그 처분의 취소를 구할 소의 이익이 있는지 논한다.

II. 기간 도과와 가중제재 규정에 관한 법리

1. 협의의 소의 이익과 제12조 제2문

(1) 협의의 소의 이익의 개념

- 소송을 제기하여 본안판결을 구하는 데 적합한 실질적 가치나 필요성을 의미하는 소송요건이다.

(2) 행정소송법 제12조 제2문

- 처분의 효력이 기간의 경과 등으로 소멸한 후에도 처분의 취소를 구하여 회복되는 법률상 이익이 있는 경우 소를 제기할 수 있다고 규정하여 예외적 구제 가능성을 열어두고 있다.

2. 가중제재 규정의 형식에 따른 판례의 태도

(1) 과거 판례의 태도

- “과거 대법원”은 가중처벌 규정의 성격에 따라 구별하는 태도를 취하였다. 가중처벌 규정이 대통령령(시행령) 형식으로 규정된 경우에는 법규성을 인정하여 소의 이익을 긍정하였으나, 부령(시행규칙) 형식의 행정처분기준인 경우에는 행정규칙에 불과하여 가중처벌의 불이익은 사실상·경제상 불이익에 불과하다고 보아 소의 이익을 부정하였다.

(2) 변경된 전원합의체 판례의 태도

- “대법원”은 전원합의체 판결을 통해 종전의 견해를 폐기하였다. 가중제재 규정이 대통령령인지 부령인지 여부와 상관없이, 행정청이 해당 기준을 준수하여 가중처벌을 과할 가능성이 실질적으로 명백한 이상 원고가 입게 될 불이익은 구체적이고 현실적인 불이익에 해당한다고 판단하였다. 따라서 제재기간이 도과한 후에도 선행 제재처분의 취소를 구할 구체적인 법률상 이익이 인정된다고 일관되게 판시하고 있다.

III. 사안의 적용

1. 영업정지기간 도과에 따른 상황 분석

- 사안에서 甲에게 가해진 1월의 영업정지기간은 이미 경과하였다. 따라서 단순히 영업정지처분의 효력 정지나 원래 지위로의 단순 복귀만을 목적으로 한다면 원칙적으로 소의 이익은 소멸한 것으로 평가할 수 있다.

2. 가중 제재 위험성과 소의 이익 유무

- 그러나 식품위생법 시행규칙 별표에 가중적 제재처분 기준이 마련되어 있고, 시장 乙 또한 향후 동일 위반 시 가중처벌이 내려진다는 점을 명확히 안내하였다. 변경된 “대법원 전원합의체 판결”의 법리에 의할 때, 이 제재처분 기준이 비록 부령 형식인 식품위생법 시행규칙에 규정되어 있더라도 행정청인 乙이 향후 처분 시 이를 준수하여 가중처벌을 내릴 실질적 위험은 현실적이고 구체적이다. 따라서 甲은 1월의 영업정지기간이 경과하였더라도 가중적 제재의 위험이라는 장래의 확실한 불이익을 제거하기 위하여 선행 영업정지처분의 취소를 구할 협의의 소의 이익을 명백히 가진다.

IV. 결론

- 사안에서 甲이 乙의 1월 영업정지처분이 완전히 경과한 후 소송을 제기하였더라도, 당해 처분의 취소를 구할 협의의 소의 이익은 인정된다. 식품위생법 시행규칙상 가중처벌 기준이 존재하여 장래에 불이익을 입을 구체적이고 실질적인 위험이 현존하기 때문이다. 따라서 법원은 제재기간이 경과하였다는 이유로 소를 각하해서는 안 되며, 甲의 소송에 대하여 본안 심리를 개시하여 청구의 당부를 판단하여야 한다.